

법, 규범성, 그리고 규칙 준수의 동기에 대한 관행론적 이해*

양선숙**

<국문초록>

레슬리 그린(Leslie Green)은 관행론에 대해 규범성, 권위, 복종의무 등의 핵심적 법현상을 충분히 설명하지 못한다고 비판했다. 법규칙은 인간 행동의 배제적 이유, 즉 여타의 모든 타산적 이유를 압도하는 이유로 작동하는 데 반해, 데이비드 루이스(David Lewis)의 이론에 영향을 받아 정식화된 관행론은 왜 사람들이 법규칙에 따르는가를 설명하면서 타산적 이유들 중 하나인바 자기이득 개념에 호소하고 있고 따라서 법규칙의 저러한 우월적 지위를 설명할 수 없다는 것이다. 본고에서 필자는 그린의 비판은 통상적 관행론의 경우에만 해당되며, 근대 사상가 흄(David Hume)이 제안했던 관행론에는 해당되지 않음을 보여주고자 한다. 재산권규칙의 관행 성립과 관련하여 제안된 흄의 관행론은 두 부분으로 구성된다. 하나는 어떤 조건 하에서 사람들이 재산권규칙의 관행을 정립하게 되는가에 대한 기술적 연구이고, 다른 하나는 사람들이 규칙 준수행위를 왜

* 이 논문은 2012학년도 경북대학교 학술연구비에 의하여 연구되었음.

** 경북대학교 법학전문대학원 부교수.

*** 투고일자 2012년 11월 12일, 심사일자 2012년 12월 10일, 게재확정일자 2012년 12월 10일.

정당하다고 평가하고 그에 따라 자신들의 행동을 조정하는가에 대한 연구이다. 본고는 흄의 관행론을 셸링 포인트(Schelling Points)와 같은 현대 게임이론의 개념들을 빌려 재구성하고자 했고, 흄에서 규칙 준수행위는 의무감(Sense of Duty)이라는 내적 동기에 따른 행위이고 따라서 단순히 외부적으로 관찰 가능한 행위가 아님을 보여주고자 했다.

I. 서 언

레슬리 그린(Leslie Green)은 법실증주의의 일종으로서의 관행론에 대해 관행론은 법의 규범성, 권위, 복종의무 등 법현상의 핵심 요소들을 충분히 설명할 수 없으며, 이 요소들은 관행이라는 사회적 사실 또는 관행 형성과 결부된 일련의 사실들에 조화해서는 충분히 해명될 수 없다고 비판한다.¹⁾ 그린이 주목하는 것은 법이 인간 행위에 고유하게 작동하는 방식, 즉 여타의 모든 타산적 이유들(Reasons)을 압도하는 이유로 작동하는 방식이다. 법은 복종을 엄중하게 요구하고, 시민은 법규정에 따를 의무를 짊어진다. 법은 그 자체로 행위의 이유가 되는 소위 배제적 이유(Exclusionary Reason)로 작동한다. 타산적 이유들은 아무리 산처럼 쌓아놓는다고 해서 법규칙이 법의 이름으로 갖는 권위보다 우선시되지 않는다. 때로는 타산적 숙고에 반함에도 법에 순응해야 한다는 것이 법복종 의무의 요체이자 법의 권위이다. 그러나 관행개념에 호소해서는 이를 설명할 수 없다. 많은 관행들은 구속적이지 않다. 공용화폐를 사용하고, 공용어를 구사하고, 같은 달력을 사용하는 관행은 우리의 실천이성에 아무런 제한도 가하지 않는다. 우리가 이런 관행들을 채택하는 것은 의무에 기인해서가 아니라 타산적 고려에 의해서이다.²⁾

필자는 그린의 비판이 내용상으로는 옳지만 모든 종류의 관행론에 해당되는 것은 아니며, 논문에서 ‘통상적 관행론’이라고 잠정적으로 명명되는 유형에만 국한된다는 점을 밝히고자 한다. 필자는 근대 사상가 흄(David Hume)이 재산

1) Leslie Green, “Positivism and Conventionalism”(1999), *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* vol.12 no.135, 35면.

2) Leslie Green(1999), 44면.

권규칙의 성립과 관련하여 제안했던 관행론을 검토할 것이다.³⁾ 흄은 현대 게임이론의 한 분야인 조정이론(Coordination Theory)의 선구자로 간주되는데, 그에 따르면 법규칙은 별도의 입법자나 조직체 없이 개인들이 일정한 인류학적, 자연적 조건 하에서 행하는 전략적 상호반응이 일치되게 수렴하면서 출현한다. 흄은 사람들이 자기이득을 추구하는 과정 중에 서로의 행동을 함께 ‘조정함으로써’ 성립하는 행위의 ‘일치’(Agreement)라는 의미로 ‘관행’(Convention)이라는 표현을 썼고, 관행이야말로 사회규범의 원천이라고 보았다.⁴⁾

일견(一見) 흄의 관행론은 그린의 비판이 유효한 듯 보일 수 있다. 그의 이론은 일련의 인류학적, 심리학적 사실을 동원한다. 그는 자원의 희소성, 물질적 재화에 대한 인간의 탐욕, 협동의 이익에 대한 경험적 인지 등에 기초하여 재산권 관행의 성립을 설명한다. 그러나 그의 이론은 그린의 비판을 넘어서 있다. 그는 재산권규칙의 성립에 대해 발생적, 기술적 설명을 제시하지만 동시에 규칙 준수행위의 규범성 내지 의무감에 대한 해명이 별도로 필요하다는 점을 알고 있었다. 그는 일정한 행동 유형이 어떻게 관행으로 정립되는가의 문제와 별개로 왜 우리가 그러한 행동을 정당하다고 판단하고 그에 따라 행동하는가의 문제를 다루었다. 그는 하트가 오스틴 식(式)의 법실증주의를 비판하면서 강조했다. 바 수범자의 ‘내적 관점’과 비견될 수 있는 행위의 내적 동기의 측면을 고려했고, 규칙 자체에 대한 존경 내지 의무감이 그 어떤 자연적 성향이나 타산적 숙고보다 우월적으로 작동할 때 재산권 규칙의 관행이 성공적으로 유지될 수 있다고 보았다.

3) David Hume, *A Treatise of Human Nature* (1978), ed. L. A. Selby-Bigge, Oxford University Press. 이하 T로 약칭; *Enquiries Concerning Human Understanding And Concerning Principles Of Morals* (1975), ed. L. A. Selby-Bigge, Open University Set Book. 이하 E로 약칭.

4) 흄에서 ‘Convention’의 1차적 의미는 ‘Areement,’ 즉 ‘일치’라는 의미이다(T490). 양선숙, “흄의 정의론 연구”(2010), 『법학연구』 제51호, 부산대학교 법학연구소, 360-361면. 이는 왜 그의 관행론이 현대 ‘조정’(Coordination) 이론의 선구자격으로 간주되는가의 이유이기도 하다. 우리말의 ‘관행’은 과거로부터 현재까지 실행되어 와서 굳어진 행동유형이라는 뜻이 강한 데 반해, ‘일치’로서의 ‘Convention’에는 원칙적으로 단 1회적인 행동의 일치도 포함된다. 이렇게 일치되게 성립한 일정한 행동유형이 시간의 경과에 따라 다수에 의해 지속적으로 행해지면, 우리말에서의 ‘관행’이 뜻하는 ‘굳어진’ 행동유형이라는 함축이 성립한다. ‘Convention’의 2차적 의미이다.

본고의 목표가 흄의 관행론이 얼마나 성공적인지를 보여주는 데 있는 것은 아니다. 우리는 흄의 이론이 비록 그린의 비판을 넘어서기는 하지만 그렇다고 완전한 이론은 아니며, 이는 그의 이론이 관행론 이어서라기보다는 그의 이론 내에 법복종 의무와 관련하여 조화되기 힘든 두 가지 시각이 포함되어 있기 때문임을 살펴보게 될 것이다.

II. 통상적 관행론

1. 관행논제

일반적으로 관행론은 법현상을 일련의 사회적, 행태적 사실로 환원하여 설명하고자 한다. 관행론은 다양한 맥락에서, 다양한 관점에서 이야기될 수 있다. 법현상 일반에 대한 포괄적 환원론으로서(이를테면, 법규칙은 관행의 한 종류라는 주장) 논해질 수도 있고, 특수하게는 하트의 논의에서처럼 승인율의 관행적 성격을 중심으로도 이야기될 수 있다(승인율은 관행적 규칙의 일종이라는 주장). 본고에서 다룰 관행론은 전자보다는 특수하지만(그 이상을 말한다는 점에서), 후자보다는 덜 특수한(법규칙 일반에 대한 이론이라는 점에서) 관행론이다. 우리는 이를 ‘통상적 관행론’이라고 명할 것인데, 이 관행론의 기본논제는 ‘관행’으로 불리는 것에 관한 규정이다.

관행논제(Convention Thesis)⁵⁾

일정 행동유형 B는 관행이다. iff

CT1. 대부분의 사람들이 행동유형 B에 따라 행동한다.

5) 이 ‘관행논제’는 데이비드 루이스(David Lewis)가 정식화한 관행모형을 다소 단순화한 것이다. David Lewis, *Convention*(1969), Cambridge: Harvard University Press, p.78. 루이스는 흄의 관행개념을 최초로 게임 이론적으로 정식화하였고, 이후의 연구자들은 루이스의 정식을 거의 그대로 사용하고 있다. Margaret Gilbert, “Notes on the Concept of a Social Convention”(1983), *New Literary History* 14(02), 229면; Leslie Green, “Authority and Convention”(1985), *The Philosophical Quarterly* vol.35. No.141, 332면.

CT2. 사람들이 B에 따라 행동하는 이유는 다른 사람들이 행동유형 B에 따라 행동한다는 조건 하에서 자신 역시 그렇게 행동하는 것이 이득이 되기 때문이다.

우리말의 ‘관행’에 함축되는 반복성은 CT1의 ‘대부분의 사람들’에 함축된다. 반복성은 다수의 사람들이 행동유형 B에 따라 행동할 때 관찰되는 속성이므로 각 개인으로서는 일생 단 한 번 또는 기껏해야 서너 번 따라하는 행동이어도 그 행동은 관행이 될 수 있다. 예컨대, 일생 단 한 번 결혼식을 올리는 사람이어도 결혼관행에 좇아 결혼식을 진행할 수 있다. CT2는 사람들이 관행적 행동을 하는 ‘이유’와 연관된다. CT2는 행동의 이유를 일정한 인지된 사실, 즉 타산적 이유에 조회하여 설명한다. 통상적 관행론은 CT1에 의해 하트의 승인율과 관련하여 거론되는 관행론보다는 일반적이고, CT2에 의해 통상적 관행론보다는 특수하다. 이제 CT1과 CT2에 의하면, 관행적 행동은 다음 요소들을 만족시킬 때 성립한다.

관행논제*(Convention Thesis*)

일정 행동유형 B는 관행이다. iff

CC. 대부분의 사람들 각자의 행동이 행동유형 B로 수렴된다.

CG. 행동유형 B로의 수렴을 통해 각자는 이득을 얻는다.

CS. 각자는 CG에서의 이득에 대해 알고 있다.

CR. CS에서의 자기이득에의 앎은 각자 행동유형 B에 따라 행동하는 이유가 된다.

위의 네 가지 요소는 통상적 관행론에서의 ‘관행적’ 행동이 타산적 행동, 즉 이해득실의 계산 하에 행해지는 것임을 뜻한다. 어떤 행동이 타산적이라는 것은 행위자가 그런 행동을 하는 ‘이유’에 관한 주장으로서, CR은 관행적 행동의 이유에 관한 주장이다. CG에서의 ‘이득’은 단기적 이득뿐만 아니라 장기적 이득 내지 진정한 의미에서의 이득도 포함하며, 우리는 행동유형 B로의 수렴을 통해 각자가 얻는 이득의 총합을 일컬어 ‘공동이득’이라고 말할 수 있다. 약속의 관행이나 계약의 관행이 있는 사회에서 사는 것이 그렇지 않은 사회에서 사는 것보다 더 각자의 이득에 이바지한다는 점에서 보자면 개별적인 약속 준

수행위는 비록 단기적으로는 유익하지 않아도 장기적으로는 유익하다. 그런데 약속관행이나 계약관행의 유지는 사회성원의 대다수가 실제로 약속을 지키는 것을 전제로 하므로, 만약 내가 나의 이득에 이바지하는 관행을 유지하기 위해 약속을 지키고 계약을 준수하는 것이라면 이때의 나의 약속 준수행위나 계약 이행행위는 ‘관행적’이다.

경우에 따라서는 CC, CG, CS는 만족하지만 CR이 성립하지 않을 수 있다. 다수의 사람들이 약속을 지키고 있고, 나는 다수의 사람들이 약속을 지키고 있다는 조건 하에서 나 자신도 약속을 지킨다면 유리할 것임을 알았다. 그리고 이런 상황에서 나는 약속을 지켰다. 그러나 이때 내가 약속을 지키는 ‘이유’는 타산적 이유가 아닐 수 있다. 나는 다른 이유로, 그저 약속은 지켜져야 한다는 의무감에 약속을 지키는 것일 수 있다. 이런 경우 나는 외적으로는 관행에 따른 행동을 했지만, CC~CR에 의해 규정되는 ‘관행적’ 행동을 한 것은 아니다.⁶⁾

CT2 내지 CG, CS, CR은 통상적 관행론에 특수한 성격을 부여한다. 근대 이후 국가형성이론과 법이론은 인간이 어떻게 정글과도 같은 무질서 상태를 벗어나 질서와 규범을 갖춘 상태로 진입하는가를 규명하는 것에 초점을 맞추었다.⁷⁾ 가장 널리 알려진 이론이 사회계약론이다. 여기서는 합리적 개인들이 일종의 예지적 이성능력을 통해 무질서의 극복을 위해서는 사회나 국가를 형성해야만 한다는 것을 깨닫고 사회나 국가 형성 그 자체를 목표로 하는 계약을 맺는 것으로 그려진다. 근대적 개인의 대표 속성으로 꼽히는 ‘평등’과 ‘자유’는 계약 당사자로서의 속성과 정확히 일치한다. 이에 반해 CG, CS, CR은 각 개인

6) 이 사례 자체가 통상적 관행론 자체의 위협이라고 할 수는 없을 것이다. 대부분의 사람들이 CR의 이유에 따라 행동하면 관행은 유지되고, 관행론은 그렇게 다수에 의해 행해지는 관행적 행동을 설명하기 위한 이론이기 때문이다. 하지만 타산적 이유에 따른 행동만을 관행적 행동으로 본다는 점은 흄의 관행론과의 차이를 드러낸다. 본고의 V절 및 VI절에서 보듯이, 흄에서 전형적인 관행적 행동은 타산적 이유가 아닌 의무감에 따른 행동이다.

7) ‘정글’(Jungle)이라는 표현은 데이비드 프리드만(David Friedman)으로부터 빌어왔다. David Friedman, “A Positive Account of Property Rights”(1994), *Property Rights*, Cambridge University Press, 3면. 본 논문의 많은 부분은 프리드만으로부터 영감을 받았다. 특히 프리드만이 그의 논문에서 소개하고 있는 셸링 포인트(Schelling Points) 개념은 흄이 제안하는바, 본고의 III절과 IV절에서 다루어질 현재 점유물 존중 규칙의 특성인 ‘두드러짐’(Salience)을 이해하는 데 많은 도움이 되었다.

이 염두에 두는 것이 사회와 국가 형성 그 자체가 아니라 오직 각자의 이득 실현임을 말한다. 관행론적 시각에서 질서와 규칙의 출처는 일정 영역 내의 사람들 전원이 일거에 참여하는 단일한 거대 계약이 아니라 각자의 독립적 행동들의 점진적인 수렴 현상이다. 법은 “법을 만들기로 하자!”는 거창한 이성의 소산이 아니라 자기이득 추구적인 행위자들이 행하는 개별적 행동의 결과물이다.

2. 사회규칙 논제

관행론이 완전한 법이론이 되기 위해서는 보충이 필요하다. C1과 C2는 기껏해야 관행들이 존재하고 있고, 사람들이 일정 조건에서 관행적 행동을 하고 있다는 사실을 언급할 뿐이다. 물론 이런 식으로 ‘관행’을 논하는 것도 유의미할 수는 있다. 관행에 대한 사회학적이거나 인류학적 고찰이 그러할 것이다. 하지만 법과 관행은 개념적으로 구분되며, 관행 일반에 대한 이론이 동시에 법에 대한 이론이 되기 위해서는 보충이 필요하다.

사회규칙 논제(Social Rule Thesis)

S1. 법규칙을 포함한 사회규칙은 CT에서 규정된 관행의 하위 집단이다.

S2. 대부분의 사람들이 법에 따라, 또는 법규칙 S에 따라 행동한다.

S3. 사람들이 법에 따라, 또는 법규칙 S에 따라 행동하는 이유는 다른 대부분의 사람들이 법에 따라, 또는 법규칙 S에 따라 행동한다는 조건 하에서 자신 역시 그렇게 행동하는 것이 이득이 되기 때문이다.

S1은 연구자들에 의해 다각도로 주장된다. 타산적 합리성의 소유자들 간에 성립하는 수렴적 행동패턴이 사회규칙의 일부가 되는 데 상정되는 연결고리 중 하나는 진화론이다.⁸⁾ 상호 수렴적으로 행동하여 질서를 이루면서 사는 집단은 그렇지 않은 집단보다 환경 적응력이 높으며, 질서 부합적 행동유형은 시간의 경과에 따라 서서히 사회적 ‘관행’으로 변모하고 규범성이 수반된다. S2

8) David Friedman(1994), 11-13면.

과 S3은 CT1, CT2의 적용 예이다. 사람들이 법규칙에 자신의 행동을 맞추는 것 역시 자기이득에 관한 숙고를 통해서 이고, 법규칙을 따르는 것은 자기이득을 위한 일종의 수단이다. 즉 자기이득이 법복종의 동기이다.

S2, S3은 법복종에 두 가지 차원이 있음을 말해준다. 하나는 특정 법규칙 S에 순응하는 것이고, 다른 하나는 사법체계 전반에 따르는 것이다. 전자의 복종과 후자의 복종은 서로 동일하지 않을 수 있다. 즉 특정 법규칙 S에 따르는 행동이 비록 자기이득에는 부합하지 않지만 사법체계 전반으로서의 ‘법’이라는 차원에서 보면 자기이득과 부합하는 것일 수 있다. 이때 후자의 복종 근거는 앞서 말한 장기적 관점 또는 진정한 의미에서의 자기이득이다.

3. ‘법의 이름으로’

이미 말했듯이, 통상적인 관행론에 대한 비판은 법의 고유한 속성인 규범성 내지 법복종의무의 설명에 실패한다는 것이다. 이 비판이 맞다면, 다음 비판 역시 관행론에 대해 제기될 수 있다.

첫 번째, 통상적 관행론은 나쁜 관행과 좋은 관행을 구분할 수 없다. CC~CR을 만족하여 ‘관행’으로는 분류되지만 규범성을 갖는다고는 할 수 없는 행동규칙이 가능하다. 만약 우리에게 법이론으로서의 관행론이 있어야 한다면, 그것은 관행 일반에 대한 이론에서 그치는 것이 아니라 ‘좋은 관행’을 적절하게 설명하는 것이어야 할 것이다.

두 번째, 규범적 행위임에도 CC~CR에서 규정되는 관행에 포섭되지 못하는 것들이 있다. 예를 들어, 독배를 든 소크라테스의 행동은 진정한 의미에서의 자기이득 개념을 동원해도 ‘관행적’ 행위라고는 말해질 수 없는 성격의 것이다. 관행론에서의 자기이득은 세속적인 의미에서의 자기이득, 편익으로서의 자기이득이고, 이런 세속적 의미에서의 자기이득 개념은 아무리 확대 해석되어도 소크라테스의 행동을 포섭할 수 없다.

세 번째, 이는 두 번째와도 연관된 것인데, 통상적 관행론은 법복종의 동기를 타산적 숙고에 둬으로써 법규칙 준수행위와 무임승차 행위를 똑같이 합리적인 것으로 만든다. 타산적 숙고에 따르면, 경우에 따라서는 법에 복종하는 것만큼이나 법에 복종하지 않는 것도 옳다.

우리는 IV절에서 흄의 관행론이 이러한 비판에 대해 어떻게 답할 수 있는가를 검토할 것이다.

III. 흄의 관행론

1. 몇 가지 모델들

먼저, 흄에서 발견되는 몇 가지 관행모델들을 살펴보자.

(1) 노 짓기 모델

흄은 관행 성립에는 명시적인 언어적 약속이 불필요하다는 점을 보이기 위해 노 짓기 예를 든다(T490). 멀리 보이는 섬으로 다가가기 위해 함께 노를 젓는 이들은 명시적인 약속 행위 없이도 자신에게 유리한 결과를 얻고자 마음을 합쳐 일치되게 노를 젓는다. 이 모델은 각자의 이득의 총합으로서의 공동의 이득(CG), 이에 대한 공동의 인지(CS), 그리고 이에 기반한 행동의 일치(CC)로 구성된다. 노 짓기 모델은 흄이 사용하는 ‘일치’로서의 관행의 의미를 잘 드러내지만 이 일치는 일회성이라는 점에서 시간적 지속을 두고 기존의 것이 된다 고 하는 관행 일반의 반복성 요소가 없다.

(2) 공용화폐 및 공용어 모델

흄은 공동의 척도를 도입하여 사용하는 것 역시 사람들 간의 일치된 행동이라는 점에서 관행의 일종으로 본다(T490). 그가 사회계약론을 반대한 이유 중 하나는 계약은 언어 사용을 전제한다는 점과 관련되어 있다. 사회계약은 계약의 일종으로서, 명시적 발화행위로서의 약속행위를 통해 이뤄지는 것이고, 우리는 언어사용을 먼저 설명하지 않고서는 계약을 온전하게 설명할 수 없다. 흄은 우리가 언어를 도입하여 사용하게 되는 과정을 언어사용의 관행이 성립하는 과정이라고 본다. 같은 단어로 같은 대상을 지시하고 같은 의미를 부여하는 것에 있어서의 일치가 바로 언어의 기원이다. 화폐 사용 역시 마찬가지이다. 화폐사용 모델과 언어사용 모델은 노 짓기 모델과 달리 대다수의 사람들 간에

서 관찰되는 수렴적 행동이라는 조건을 만족시킨다.

(3) 재산권 규칙 모델

이 모델은 통상적 관행론에서의 관행개념에 가장 잘 부합하며, CC~CR을 만족시킨다. 이는 그의 재산권 규칙의 성립에 관한 이론이 왜 게임이론의 원형으로 간주되는가의 이유이기도 하다. 또한 재산권 규칙 모델은 우리가 조명하고자 하는바 흄의 관행론과 통상적 관행론 간의 차이점을 잘 드러낸다. 바로 규범성 요소이다. 절대행위는 비록 당장 눈앞에서 굶어 죽어가는 가족을 구하기 위한 것이라고 해도 범해서는 안 될 사회적 악덕이다. 우주의 운행이 일순간 멈추어져서 타인의 시선과 주의가 중지되고 오직 나만이 자유롭게 운신할 수 있게 되기를 바랄 정도로 극도의 궁핍에 내몰린다고 해도 나는 타인의 물건에 손을 대서는 안 된다(T491). 하지만 공용화폐나 언어를 사용하는 것에는 이러한 규범성 요소가 없다. 문법에 어긋나게 말하는 것은 무식하다는 말은 들을지 언정 무도한 행위는 아니다. 거래 상대방과 합의만 되면 교환의 잣대로 공용화폐 아닌 다른 것을 사용할 수 있고, 그렇다고 해도 무법한 사람이 되는 것은 아니다.

우리가 다루고자 하는 것은 세 번째인 재산권규칙의 성립 모델이다.

2. 재산권 규칙의 성립 관행

(1) 조 건

흄은 재산권규칙을 ‘정의의 규칙’으로 칭하는데,⁹⁾ 이 정의의 규칙들에는 타인의 재산에 대한 일반적 존중 규칙 및 최초의 재화할당 규칙, 그리고 이후의

9) 흄의 관행론은, 독특하게도, 그에게는 일종의 정의론이었다. 양선숙(2010), 359-360면. 흄이 재산권 규칙을 동시에 ‘정의의 규칙’으로 칭하는 것은 고대 키케로(Cicero)로부터의 사상사적 전승을 통해 설명될 수 있다. 다음 두 논문을 참조. James Moore, “Utility and Humanity: The Quest for the Honestum in Cicero, Hutcheson, and Hume”(2002), *Utilitas* 14(03); Neal Wood, “The Economic Dimension of Cicero’s Political Thought: Property and State”(1983), *Canadian Journal of Political Science* Vol.16, No.4.

소유권 확정규칙들이 포함된다. 흄은 재산권규칙들 일반의 정립 필요성 및 가능성을 다음과 같은 일반조건 하에서 도출했다.

(s) 객관적 조건: 재화의 희소성 및 불안정성

(o) 주관적 조건: 이기심과 제한적 관용

(s)과 (o)의 조건이 재산권규칙의 성립과 직접 연결되는 것은 아니다. 이 조건들과 재산권규칙의 성립을 매개하는 것은 노동협동체, 즉 ‘사회’의 형성 필요성이다. (s) 및 (o)은 사회의 필요성 및 가능성의 조건이며, 사회의 형성과 유지 는 재산권규칙들의 정립을 요구한다.

먼저, 흄은 필요와 욕망의 충족이라는 점에서 볼 때 우리에게 자연적으로 주어 진 재화는 매우 희소하다는 사실을 지적한다. 재화의 희소성 문제를 해결하는 유일한 방법은 노동협동체를 구성하는 것뿐이다. 노동연합을 통해 협업과 분업이 이뤄지면, 더 많은 양질의 재화를 생산할 수 있게 되고, 상호부조를 통해 삶의 안녕을 꾀할 수 있다(T485).¹⁰⁾

(o)는 인간의 자연적 성향에 관한 것이다. 흄은 사람들이 이기적 탐욕의 화 신이기도 하지만 동시에 제한적 관용(Limited Generosity)을 발휘한다고, 즉 가족이나 친구, 지인 등 주변 사람들에게 제한된 이타심을 발휘한다고 본다 (T494). 제한적 관용은 사람들이 노동협동의 중요성을 깨닫는 데 있어서 중요한 역할을 수행한다. 제한적 관용이 주로 발휘되는 장소는 가족으로서, 사람들은 가족 내에서의 협동작업을 통해 협동이 가져다주는 이득을 배운다. 즉, 상호 노동을 연합함으로써 재화의 희소성 문제가 해결된다는 것을 경험한다 (T593; 496).

하지만 (s) 및 (o)는 부분적으로는 협동체 형성의 방해물이다. 한 개인이 지닌 물질적 재화는 그의 심신과 달리 그로부터 쉽게 분리되어 이리저리 이전이

10) 흄은 인간의 욕망구조가 사회 안에서 변화를 겪는다는 점을 알고 있었다. 사회 안에서 사는 삶은 인간의 필요(Wants)를 증진시킨다. 하지만 그것을 보충하고 남을 만큼 필요를 충족시킬 수 있는 인간의 능력(Abilities) 역시 사회 안에서 증진된다. 그 결과 인간은 야만적이고 고독한 상태(Savage and Solitary Condition)에서보다 사회 안에서 더욱 행복하다(T485).

가능하고, 이는 인간의 이기심과 결합하여 약탈의 유혹을 낳아 사회 형성을 방해한다. 제한적 관용 역시 마찬가지이다. 가족과 친구를 위해 기꺼이 희생을 감수하는 것은 더 큰 규모의 사회 성립을 방해한다(T487).

(s) 및 (o)의 각 요소가 사회 성립과 갖는 관계를 표로 표시하면 다음과 같다.

[표 1]

재산권 관행의 성립 조건		사회 성립과의 관계	
		정(正)의 관계	부(否)의 관계
(s) 객관적 조건	재화의 희소성	✓	✓
	재화의 비안정성		✓
(o) 주관적 조건	이기심	✓	✓
	제한적 관용	✓	✓

사회 성립을 위해서는 네 가지 요소들 중 사회 성립과의 관계에서 오직 부(否)의 관계에만 서 있는 것, 즉 재화의 비안정성을 제거하는 것이 필요하다. 흄은 이 일이 사람들이 서로 공격하지 않음으로써, 즉 타인으로 하여금 그가 지닌 물건을 안정적으로 향유하는 것을 허용함으로써 가능하다고 말한다. 타인의 물건을 함부로 빼앗지 않음으로써, 마치 그 자에게 고유하게 속해 있어서 이동이 불가능한 그 자의 심신과 유사하게, 물건 역시 그 자에게 고유하게 속해 있는 것으로, 즉 그의 재산으로 간주한다는 것이다.

(2) ‘공동의 인지’

흄의 주장은 궤변처럼 들릴 수 있다. 주어진 조건들의 결합—재화의 희소성과 비안정성, 이기심 등의 결합으로 초래되는 상호약탈과 공격이 단지 약탈하지 않음으로써, 즉 공격하지 않음으로써 개선될 수 있다는 것은 동어반복적인 이야기가 아닌가? 주어진 삶의 조건을 어떻게 제거할 수 있는가?

흄은 이에 대해 타인으로 하여금 그가 지닌 재화를 향유하게 하여 재화의 비안정성을 제거하는 것은 이기심의 제거를 통해 이뤄지는 것이 아니라, 이기심의 방향에 변화를 주는 것(Alteration of Direction)을 통해 가능하다고 주장한다(T492). 이기심은 그대로 보유하면서, 그에 제한을 가하여 협동체 구성에 장애물이 되지 않도록 한다는 것이다. 이 새로운 방향 설정은 다음 계기들로 이뤄진다.

(c) 간주관적 조건

- c1. 비공격이 유발하는 공동의 이익에 대한 공동의 인지(Common Sense)
- c2. c1의 상호 표현
- c3. 조건적인 비공격의 결의의 표현
- c4. c1 및 c2에 근거한 상호 행동의 기대
- c5. 비공격 행위에서의 일치(Agreement)
- c6. 모방 및 시간의 경과에 따른 관행의 정립

위의 조건들은 앞서의 관행논제*의 조건들과 유사하지만 다른 점도 있다. 앞서의 조건들은 ‘관행’에 대한 일반적 개념정의, 즉 우리가 현재 관행이 있다고 말하기 위해서는 어떤 조건의 만족이 필요한가에 관한 것이지만 위의 간주관적 조건은 어떤 상황에서 관행이 성립하는가에 관한 것들이다.

이미 언급되었듯이, c1의 공동의 이득에 대한 공동의 인지는 원초적 사회인 ‘가족-사회’ 안에서 얻어진다(T496; 593).¹¹⁾ 가족 내에서의 노동협동을 통해 더 많은 재화를 획득했던 경험은 사람들로 하여금 더 큰 공동체를 구성하도록 하는 원동력이 된다. 또한 사람들 각자는 자신이 협동의 이익을 알고 있음을 서로 표현함으로써(c2), 자신뿐 아니라 다른 사람들도 이 이익을 알고 있다는 것을 알게 된다. 그리고 이러한 협동의 이익의 표현에는 각자 스스로 자신의 행동을 협동의 이익에 따라 조정할 것이라는 결의(Resolution)가 동반한다(c3). 이 결의는 조건적이다. 사람들은 “당신이 공격하지 않는 한, 나는 당신을 공격하지 않을 것이다”라는 결의를 서로에게 표현하며, 또한 이에 근거하여 서로의 행동에 대한 기대와 예측이 발생한다(c4).¹²⁾ 주목할 점은 이때의 기대와 예측

11) 흄에서 노동 협동체, 즉 사회를 구성하는 사람들은 이미 가족이라는 원초적 형태로서의 사회 안에서 살아왔던 자이다. 이 점에서 흄은 ‘고독한 자연인’ 일반을 사회 구성의 당사자로 상정했던 홉스나 루소와 다르다. 흄에서 고독한 개인의 모습은 기존의 사회로부터 추방되거나 떨어져 나와 새로운 사회를 형성하는 경우에 국한된다(T503). 양선숙(2010), 373면.

12) 흄은 노 젓기 모델을 예로 들면서 공동의 이득에 대한 앎 및 결의의 표현, 그리고 이로부터의 상호 기대와 예측이 언어 사용을 전제로 하는 ‘약속(Promise)’ 없이 발생한다는 점을 강조한다(T490). 하지만 재산권 규칙의 정립에서 요구되는 바 공동의 이득에 대한 공동의 인지를 서로 표현한다거나 비공격의 결의를 표현하는 것은 여전

은 서로에 대한 동형적 특성을 전제한다는 점이다. 나는 나의 합리성에 비추어 상대방의 행동을 예측하고 기대한다. 나는 내가 과거경험을 바탕으로 행동을 조정하듯이 상대방 역시 그러할 것이라고 판단한다. ‘그리하여’ 나와 상대방은 비공격의 행위에서의 ‘일치’(Agreement)를 이룬다(c5).¹³⁾ 평화의 행동유형은 모방을 통해 느린 걸음(Slow Progression)으로 규모가 확대될 것이고, 시간의 경과에 따라 이윽고 사회적 관행으로 정립된다(c5)(T490).

(3) 현재 점유물 존중의 규칙

하지만 흄은 타인의 재산을 존중하여 공격하지 말라는 평화의 관행은 일반 조항의 성격을 갖고 있고 그것이 실제로 실행되기 위해서는 각자가 무엇을 상대방의 재산으로 간주하여 상대방으로 하여금 그 평화로운 향유를 허용하게 할 것인가에 관한 규칙, 다시 말해서 재화의 최초 할당 규칙이 필요하다는 점을 지적한다(T501; 502).¹⁴⁾ 흄이 제안하는 재화의 최초 할당 규칙은 ‘현재 점유물 존중의 규칙’이다. 즉 재화의 최초 할당이 문제시되는 바로 그 시점, 즉 상대

히 언어 사용을 요구하는 듯이 보인다는 점에서 핀 콜린(Finn Collin)은 흄의 설명이 만족스럽지 않다고 본다. Finn Collin, *Social Reality* (1997), Routledge, 198면. 이러한 콜린의 평가는 흄의 관행론이 단적으로 관행 그 자체를 설명하기 위한 것이라는 이해를 바탕으로 하고 있다. 만약 흄의 관행론이 재산권 관행을 설명하기 위한 것이 아니라 단적으로 관행 그 자체의 설명을 위한 것이었다면 콜린의 지적은 옳다. 그러나 그의 이론은 어디까지나 우선적으로는 재산권 규칙준수의 관행을 설명하기 위한 것이었고, 따라서 재산권 관행의 성립 이전에 먼저 언어 도입의 관행이 성립해 있을 가능성을 배제할 수 없으므로 재산권 관행의 성립에 필요한 저러한 표현들이 언어의 사용을 요구한다고 해서 흄의 설명이 불완전하다고 할 수는 없을 것이다.

13) 앞서 각주4에서도 언급되었듯이, c5에서의 ‘일치’는 ‘Agreement’의 역어로서 흄은 이 대목에서 ‘Convention or Agreement’라고 함으로써 ‘Convention’과 ‘Agreement’를 동의어로 사용한다. 흄의 이런 용어법은 ‘Convention’의 어원이 ‘함께 가다’는 의미의 라틴어 ‘Convenir’라는 점을 생각하면 쉽게 이해될 수 있다. 양선숙(2010), 360-361면.

14) 흄은 일반적 조항으로서의 재산권 존중의 규칙을 실제로 적용하는 데 필요한 세부 규칙으로 현재 점유물 존중의 규칙 외에도 다음 세 가지를 들었다; (1) 선점 및 시효 취득, 과실취득, 상속의 규칙(T505-513), (2) 동의를 통한 재산 양도의 규칙(T514-516), (3) 약속과 계약을 통한 재산 양도의 규칙(T516-525). 양선숙(2010), 376면.

방의 물건을 약탈하지 않겠다는 태도를 취하게 되는 바로 그 시점에 각자 점유하고 있는 물건을 각자의 것으로 간주하라는 것이다. 흄은 재화의 최초 할당 규칙이 갖추어야 할 조건들로 다음을 제시한다(T502; 503).

MC. 갈등의 최소화

ME. 비용의 최소화

흄에 따르면, 현재 점유물 존중의 규칙은 위의 두 조건을 가장 잘 만족한다. 현재 점유물 존중의 규칙은 한편으로는 사람들이 기왕에 자신의 수중에 있는 물건에 갖게 되는 애착관계를 반영한다는 점에서 새로운 갈등을 유발하지 않으며, 다른 한편으로는 그 내용이 현재 각자의 수중에 있는 물건을 각자의 것으로 하라는 것인 만큼 그 채택과 실행에 비용이 가장 적게 드는 규칙이다.

IV. 게임 이론적 재구성

1. 두 가지 문제

흄의 설명은 두 가지 의문을 낳는다. 첫 번째는 c1와 c2를 바탕으로 c3가 성립하게 되는 ‘**그리하여**’의 기제이다. 각자가 협동이 가져다주는 이득을 알고 있고 또한 상대방이 나와 같은 합리성의 소유자임을 전제한다고 해도, 반드시 상호 평화가 초래되는 것은 아니다. 왜 흄의 인간은 흄스의 바보가 아닌가? 어떻게 나의 이기심의 자제와 너의 이기심의 자제가 함께 발생하여 행위에서의 일치를 이뤄내는가? 나의 평화의 행동전략이 나를 희생양으로 만드는 어리석은 것이 아니라는 보장이 어디서 성립하는가?

두 번째는 현재 점유물 존중의 규칙이 갖는 설득력의 문제이다. 일반적으로 우리는 배분 문제와 관련하여 배분 기준의 정당성을 요구한다. 우리가 배분 문제를 중시하는 이유는 ‘정당한’ 몫의 배분에 관심을 갖고 있기 때문이다. 우리가 원하는 것은 힘의 논리나 우연적인 운(Luck)에 의한 할당이 아니라 정당한 배분의 규준에 따라 이뤄지는 배분이다. 그런데 현재 점유물 존중의 규칙은 단

순한 사실 상태인 ‘점유’에 따라 재화가 할당되어야 한다고 주장하며, 이는 정당성 요구와 배치되는 매우 자의적인 기준으로 보인다.

2. ‘그리하여’

(1) 최초의 기회

‘그리하여’의 기제를 검토하기 위해 다음 표를 보자. [표 2]는 이해 타산적 합리성을 지닌 두 사람이 상대방의 물건에 대한 공격이나 존중이나의 두 가지 선택지 중 무엇을 택하는 것이 합리적인가를 보여준다.

[표 2]

		Y	
		i(약탈)	ii(평화)
X	i	0, 0	5, 0
	ii	0, 5	10, 10

위 표에서 (ii, ii)는 (i, i)와 함께 내쉬 평형상태(Nash Equilibrium)이다. 이 두 상태에서 양 당사자는 상대방이 전략을 변경하지 않는 한 자신의 전략을 변경하지 않는다. 사정변경이 없는 한, 상호 평화가 지속되든가(ii, ii), 공격상태가 지속되든가(i, i)이다. (i, ii)와 (ii, i)은 비평형상태이다. 내가 평화전략을 택한다면 상대방 역시 그러하리라는 보장이 없는 한, 전자에서는 Y가, 후자에서는 X가 상대방의 공격에 공격으로 응대하고자 할 것이고, 이들은 자연스레 (i, i)의 상태로 접어들 것이다.

문제는 (i, i)이 아닌, 그보다 나은 상태이자 최적 상태인 (ii, ii)가 도래할 수 있는 가능성의 확보이다. X와 Y는 어떻게 상대방의 선의에 대한 전망과 신뢰를 가질 수 있는가? 이들이 서로의 선의를 믿을 수 있는 객관적 장치는 아직 없다. 설령 언어를 통해 서로의 의사 확인이 가능하다고 해도, 그것이 거짓된 메시지가 아님을 배제해주는 장치는 없다. 바로 전형적인 죄수의 딜레마 상황이다.

흠이 호소하는 것은 ‘최초의 기회’(First Opportunity)라는 우연성 기제이다.

그는 정의의 행동을 하게끔 유인하는 데에 앞서 언급된 c1~c6의 조건들 외에 다른 무엇인가가 필요하다고 보지 않았다. 즉, 저러한 조건들이 갖추어지면 누군가는 평화의 행동을 할 것이고, 이 행동은 하나의 본보기(Example)가 되어 타인의 평화 행동을 유도할 것이라는 것이다. 중요한 것은 이 ‘최초의 기회’는 사람들이 일방적인 약탈이나 상호 약탈이 가져오는 좋지 않은 결과에 대한 반복된 경험을 두루 거친 후에 출현한다는 점이다. ‘최초의 기회’에서 전제되는 상대방의 선의에 대한 기대는 일종의 궁박(窮迫)의 요청이다. 상호 공격이 서로를 궁핍하게 만든다는 것을 알게 되었을 때 누군가가 먼저 보이는 평화의 결의와 행동은 사람들의 마지막 호소처이다. 물론 거짓된 표현도 있고 거짓된 결의도 있을 것이지만, 누군가 한 사람이 진의를 표현하고 그것을 실행에 옮긴다면, 이에 따라 상대방도 자신의 결의를 실행한다.

우연한 본보기에 호소한다는 것을 이론적 약점이라고 할 수는 없다. 새로운 종의 출현은 우연한 돌연변이의 발생에 의해서이다. 두 발로 걷기 시작한 누군가의 등장으로 모든 것의 변화가 시작되었듯이, 누군가의 평화의 행동으로 인해 평화의 관행은 시작된다. 물론 관행의 우연성과 종의 출현의 우연성 간에는 차이가 있다. 전자는 합리성에 기반을 둔 ‘의도’가 개입된다. 비록 ‘우연히’ 이지만 누군가가 취하는 평화의 태도는 타산적 합리성의 산물이고, 이것이 모방되어 관행으로 발전하는 것 역시 사람들의 합리성에 의존한다. 각자의 상태를 현재보다 더 낫게 만드는 해(解)가 있음에도 그 해를 취하지 않는 것은 비합리적이며, 서로의 합리성을 믿는 당사자들은 그 해를 취할 것이다.

(2) 대략적 평등

‘그리하여’의 두 번째 계기는 대략적 평등의 가정이다. 만약 양 당사자가 대등하지 않다면, 공격이나 비공격이나 선택지가 주는 이득은 대칭적이지 않다. 지금 근면한 X가 수중에 갖고 있는 재화는 게으른 Y의 것보다는 훨씬 많지만 공격에 사용할 수 있는 완력이라는 점에서는 X가 Y보다 약하다고 해보자. 이런 경우 Y로서는 공격을 감행하여 X의 것을 취하는 것이 가장 큰 이득이고 더 합리적이다. 이들은 상호약탈로 귀결되거나([표 2]에서의 (i)), 아니면 게으른 Y는 X의 재화를 전부 다 약탈하지는 않고 일부는 남겨두어 X로 하여금 더 많은 재화를 생산하게 하고 그 산출물을 자신의 것으로 하고자 할 것이

다. 즉 노예의 출현이다([표 3]에서의 (ii,i)).

[표 3]

		Y	
		i(약탈)	ii(평화)
X	i	0, 10	11, 0
	ii	2, 9	10, 1

[표 4]

		Y	
		i(약탈)	ii(평화)
X	i	0, 10	11, 0
	ii	0, 11	10, 1

반대로, 더 많이 가진 자가 더 힘이 강한 경우[표 4], 또는 서로 힘은 대등하지만 재화 보유의 격차가 너무나 큰 경우에도 상호 평화상태는 귀결되지 않는다[표 5].

[표 5]

		Y	
		i(약탈)	ii(평화)
X	i	11, 0	11, 0
	ii	0, 11	10, 1

[표 6]

		Y	
		i(약탈)	ii(평화)
X	i	0, 10	11, 0
	ii	0, 11	10, 1

약탈에의 유혹을 약화시키는 두 가지 평등, 즉 심신에서의 대략적 평등과 재화 보유에서의 대략적 평등은 최초 재화 할당이 문제시되는 시점에서 일반적으로 성립한다고 할 수 있으며, 특히 후자는 흠에서 명시적으로 인정된다. 아직 노동 협동체가 구성되기 이전이므로 사람들이 보유하는 재화는 빈약하고 그 차이 또한 크지 않다(T539).¹⁵⁾ 또한 심신능력의 평등은 근대는 물론 현대 이론가에서도 널리 발견되는 가정이다. 홉스는 만인에 대한 만인의 투쟁이 성립하는 논거로 심신능력의 대략적 평등을 들었고, 로크는 사람들이 ‘동일한 능

15) 흠은 인디언의 예를 든다. 사회 초창기에 살고 있는 인디언들은 타인의 오두막이나 화살을 약탈하고픈 유혹이 상대적으로 약할 것이고, 사냥이나 어로에서 어쩌다 남들은 갖지 못한 물건을 갖게 되었더라도 이는 일시적인 것이므로 역시 약탈을 통한 분규의 발생은 덜했으리라는 것이다.

력’ 또는 ‘유사한 능력’을 부여받았다는 것을 전제로 삼아 자연상태에서는 지배 복종 관계가 성립하지 않음을 보여주하고자 했다.¹⁶⁾ 또한 흡사 흡스의 표현을 그대로 인용한 듯한 문장에서 하트는 사람들 간의 심신능력상의 대략적 평등을 조직화된 제재의 효능과 연결시켰다.¹⁷⁾

3. 셀링 포인트(Schelling Point)

(1) 순수조정게임(Pure Coordination Game)

흡의 주장은 순수조정게임에서의 포컬 포인트(Focal Point) 또는 셀링 포인트 개념을 통해 더욱 설득력 있게 이해될 수 있다. 먼저, 두 명이 참여하는 순수조정게임은 다음과 같이 규정된다.

$n \geq 2$ 일 때, 게임 참여자 1은 전략들의 집합 $\{s1_1, \dots, s1_n\}$ 에서 하나의 전략을 택하고, 게임 참여자 2는 $\{s2_1, \dots, s2_n\}$ 에서 하나의 전략을 택한다. 각각 택해진 전략들의 쌍을 $s1g, s2h$ 라고 하자. 이때 만약 $g=h$ 라면 두 참여자는 상을 한 개씩 받지만, $g \neq h$ 라면 아무런 상도 받지 못한다.¹⁸⁾

위와 같은 게임에서는 정확히 n 개의 내쉬 평형상태들이 존재하며, 당사자들은 이 평형상태들에 대해 무차별적이다. 즉 각 평형상태가 택해질 확률은 균등하게 $1/n$ 이고, 두 사람이 동일한 해를 택할 확률은 $1/n^2$ 이다. 셀링 포인트는 게임 참가자들이 동일한 해를 선택할 확률이 실제로는 이런 계산 결과보다 훨씬 높다는 데에서 착안된다. 각 선택지는 평형상태라는 점에서는 동등하지만 게임 참여자들이 실제로 모든 해를 동등한 비중으로 고려하는 것은 아니다. 그들은 그들이 보기에 가장 자연스럽고, 적절하고, 눈길을 잡아끄는 해를 고른다.

16) Thomas Hobbes, *Leviathan*(2002), Broadview Press, Chapter XIII, 93면; J. Locke, *The Second Treatise of Government and A letter Concerning Toleration*(2002), Dover Publications, New York, 2-3면.

17) 허버트 하트, 『법의 개념』(2001), 오병선 옮김, 아카넷, 258-259면.

18) Judith Mehta, Chris Starmer, and Robert Sugden, “The Nature of Salience: An Experimental Investigation of Pure Coordination Games”(1994), *The American Economic Review* Vol.84, No.3, Jun, 658면.

다시 말해서, 가장 비중 있게(Focal) 보이고, 두드러진(Salient) 것을 택한다.

현대 협상이론으로 유명한 토마스 셸링(Thomas Schelling)이 제안하여 유명해진 이 포컬 포인트 또는 셸링 포인트는 1차적 의미와 2차적 의미로 구분된다.¹⁹⁾ 전자는 단순히 각자 자신에게 가장 독특하게 시선을 잡아끄는 두드러진 해를 고르는 것이고, 후자는 상대방이 어떤 해를 고를 것인가를 추정하고 또한 상대방이 내가 어떤 추정을 하리라고 추정할 것인가를 추정하여 이에 근거하여 해를 고르는 것이다. 양 당사자가 같은 해를 고를 확률이 높은 것은 물론 2차적 의미에서의 셸링 포인트에서이다. 1차적 의미에서의 셸링 포인트는 단순히 각자가 자신의 눈길을 잡아끄는 해를 택하는 것이고, 2차적 의미에서의 셸링 포인트는 상대방의 시선에 두드러지게 보이는 해가 무엇일까를 고려하여 해를 택하는 것이기 때문이다. 이 점에서 후자는 전자보다 더 합리적이라고 할 수 있다.

셸링이 든 유명한 사례는 백화점에서 길을 잃어 헤어진 부부가 사전 상의 없이 서로를 만날 수 있는 곳으로 가는 게임이다. 또 다른 사례는 두 사람에게 ‘앞면’과 ‘뒷면’ 중 하나를 동시에 외치게 하여 같은 것을 외치면 상을 주는 게임이다.²⁰⁾ 게임 참가자들이 성공할 확률은 그들이 얼마나 상대방의 의사결정 전략을 알고 있고, 얼마나 유사한 의사결정 전략을 갖고 있는지에 달려 있다.²¹⁾

(2) 다른 규칙들

홉이 제안하는 현재 점유물 존중의 규칙은 일종의 셸링 포인트이다. 홉은 이 규칙이 다른 규칙보다 더 눈길을 끌고, 더 선호된다고 주장한다. 홉은 현재 점유물 존중의 규칙 외에도 다른 두 가지 규칙을 검토하는데, 하나는 효용성 규칙이고 다른 하나는 노동 규칙이다.

UR: 무엇을 누구의 것으로 할 것인가는 누가 그 물건을 가장 쓰임새 있게 사용하는가라는 효용(Utility) 차원에서 결정된다(T502).

19) Judith Mehta, Chris Starmer, and Robert Sugden(1994), 661면.

20) Thomas C. Schelling, *The Strategy of Conflict* (1980), Harvard University Press, 54-55면.

21) David Friedman(1994), 4-7면.

LR: 자연물의 일부에 노동을 혼합한 자가 그 결과물을 차지한다(T505 각주1)

흙에 따르면, UR은 좋은 규칙이 아니다. 먼저, 어떤 물건이 누구에게 가장 효용성 있게 사용되는지에 대해서는 다툼 있는 복수의 주장이 가능하며, 상호 경합되는 주장들 중 무엇이 옳은지를 공정하게 판가름해줄 수 있는 기제는 아직 없다. 경합되는 효용성 주장은 분규를 유발할 것이고, 이는 공동체 구성을 방해할 것이다(MC의 위반). 또한 효용성은 누가 무엇을 사용하는가에 따라 달라지는 개별적이고 상대적 개념이다. 하지만 각자의 것을 존중하라는 정의의 규칙은 그렇게 개별사례에서의 개별적 효용성에 따라 적용되는 성질의 것이 아니다. 정의의 규칙은 특정 물건이 특정한 누군가에게 얼마나 유용한지의 적합성(Fitness) 따위는 안중에 없다. 정의는 더욱 포괄적인 견지(More Extensive Views)에서 작동한다. 정의의 규칙은 남에게 잘 베푸는 사람에게나 인식하기 짝이 없는 구두쇠에게나 똑같이 다가가며, 설령 어떤 물건이 그 소유자에게는 아무런 쓸모가 없다고 해도 바로 그렇기 때문에 소유관계가 바뀌어야 하는 것은 아니다.²²⁾

LR에 대해서는 흙은 다음과 같이 비판한다. 첫 번째, 모든 재산권 성립에 노동의 부가가 동반하는 것은 아니다. 예를 들어, 소떼가 공유지의 풀을 뜯어 먹을 때 소떼 주인은 초지에 대한 사용권을 갖지만 이는 노동을 통해서가 아니다. 두 번째, LR은 과실취득의 논증을 차용한 것으로 순환론적이다. 자연물의 일부에 노동이 부가되었다고 해서 이를 통해 그 부가물 전체가 노동자의 것이 될 수는 없다. 노동 부가를 통해 부가물 전체가 노동자의 것이 된다고 하기 위

22) UR은 ME의 만족에도 실패한다. 이 점은 우리가 살고 있는 현재 상태, 즉 정부가 있는 상태에서 만약 효용의 원칙에 따라 배분이 이뤄지는 경우 어떤 일이 벌어질까를 생각해보면 분명하다. 뒤에서 볼 것처럼, 흙은 익숙한 사물이 주는 정서적 효과에 주목했다. 사람들은 자신의 수중에 갖고 있는 물건에 대해 강한 애착관계를 갖고 있다. UR에 따라 소유관계를 재정립한다는 것은 현재 각자가 갖고 있는 것을 박탈하여 재할당한다는 것을 뜻하는데, 각자가 자신의 현재 점유물에 대해 애착을 갖고 있다면, 그 박탈과 재할당에는 비용이 들 것이다. 수중에 쥔 것을 빼앗기지 않으려는 사람들의 의지를 통제하든가 아니면 보상을 지불하여 자발적으로 내놓도록 하든가 하여야 하는데, 이 둘은 모두 비용이 든다. 오늘날 정부가 하는 많은 일은 이 둘 중 하나에 해당한다. 즉 복지정책을 펴기 위해 세금을 거두는 일이나, 보상금을 지급하고 토지를 수용하여 학교를 건축하고 철로를 놓는 것 따위.

해서는 그 전에 이미 노동이 부가되는 그 자연물의 일부가 노동자의 것이었어야 한다. 세 번째, 노동을 ‘혼합한다’(Mix)는 것은 비유적 수사에 지나지 않는다. 노동은 물건에 혼합되는 것이 아니라 물건에 일정한 변화를 불러일으키는 것이고, 이 변화로 인해 저절로 그 물건이 노동자의 것이 되는 것은 아니다. 소유는 노동이 아니라 재산권 규칙들을 통해 규정된다.²³⁾

현재 점유물 존중의 규칙은 위의 두 규칙들보다 더 선호된다.²⁴⁾ 무엇보다도, 이 규칙은 가장 손쉽게 떠오르며(Immediately Occur), 가장 자연스럽고 편리한 방책(Most Natural Expedient)이라는 점에서 1차적 의미에서의 셀링 포인트이다. 흄은 새롭게 사회를 형성하기 위해 모인 사람들의 경우를 고려해볼 것을 제안한다(T503). 이들이 가장 먼저 해결해야 할 문제는 각자의 것을 할당하는 것이고, 이는 현재 점유물 존중의 규칙을 통해 쉽게 해결된다. 이 규칙은 손쉽게 떠오르고 쉽게 수락되리라는 점에서 ME를 만족하며, 사람들이 현재 점유물에 대한 점유자의 애착관계를 잘 반영한다는 점에서 MC를 만족한다.

점유물 존중의 규칙은 2차적 의미에서의 셀링 포인트이기도 하다. 사람들은 협동이 가져다주는 공동의 이득을 알고 있고, 이를 알고 있음을 서로에게 표현하며, 상대방이 공격하지 않는 한 나 역시 공격하지 않겠다는 결의를 공유한다. 또한 이들은 서로의 행위를 모방할 줄 아는 자들이다. 모방이 가능하다는 것은 상당부분의 공통분모를 갖고 있다는 것을 뜻한다. 모방은 동일한 행동이나 몸짓을 취함으로써 동일한 의미를 공유하는 작업이다. 사람들은 유사한 인지적

23) 양선숙(2010), 367-368면.

24) 흄에서 UR과 LR이 거부되는 또 다른 이유—어쩌면 가장 근본적인 이유—를 찾으면, 그것은 그가 재산개념을 사람들 간의 합의에 따라 변동가능한 임의적인 관계개념으로 보았기 때문일 것이다. 그는 사람과 물건의 관계가 ‘자연적인’(Natural) 것이 아니라 ‘도덕적인’(Moral) 것, 그리고 정의(=관행에 의해 채택되는 재산권규칙의 총체란 뜻에서의 정의)에 의존적인 것으로 생각했다(T491). UR과 LR은 각각 효용성과 부가 노동이라는 기준에 맞추어 재화를 할당한다는 것으로서, 누가 물건을 가장 효용성 있게 사용한다거나 누가 자신의 노동을 부가했다거나 하는 것은 사람들 간의 합의에 따라 변동 가능하지 않다. 이러한 유동적인 재산개념을 이어받은 뷰캐넌(James M. Buchanan)은 재산을 일단의 사람들에게 구체적으로 분배하는 것이나 권리구조의 일반적 특성을 정하는 것은 자유로운 개인들의 합의 대상이 아님을 들어 반대한다. James M. Buchanan, *The Limits of Liberty between Anarchy and Leviathan*(2000), pp.27-28.

내용, 유사한 표현과 결의, 그리고 모방이 전제로 하는 공통점 등으로 인해 최초의 재화 할당의 시점에서 합치된 선택지를 고를 확률이 높으며, 따라서 만약 현재 점유물 준중의 규칙이 1차적 의미에서의 셀링 포인트라면 그것은 동시에 2차적 의미에서의 셀링 포인트가 될 확률이 높다.

V. 관행과 규범성

1. 규범성 설명의 요구

(1) 두 가지 문제

이미 말했듯이, 흄의 관행론은 단순히 관행 성립에 관한 고찰만은 아니었다. 그는 재산권규칙의 관행에 대한 논의를 시작하면서 두 가지 문제를 구분한다. 하나는 재산권 규칙이 어떻게 성립하는가의 문제이고, 다른 하나는 재산권 규칙의 준수/위반이 규범적으로 승인되거나/승인되지 않는 이유의 문제이다. 전자는 외부 행태적 고찰과 기술만으로 그 답이 충분하게 주어질 수 있지만, 후자의 해명에는 수범자의 규범적 관점을 고려하는 것이 필요하다. 단순히 타인의 재산을 약탈하지 않는다는 규칙을 지키는 것과 타인의 재산을 약탈하는 것은 옳지 않다고 판단하여 규칙을 지키는 것은 다르다. 필자는 이 차이에 대한 성공적인 설명은 성공적인 법이론이 되기 위한 필수 조건이라고 생각한다. 우리에게 유의미한 법현상은 내적 자발성을 지닌 행위자를 전제한 것이고, 규범적 승인의 문제야말로 자발적 행동의 핵심적 요소이기 때문이다.²⁵⁾

25) 이와 관련하여 필자는 ‘내적 관점’이 하트 자신에 의해 충분히 체계적으로 개진되었던가 하는 의문을 갖고 있다. 그는 한편으로는 법적 의무를 ‘사람이 경험하는 압력이나 강제의 감정’으로 이뤄진 것으로 오해하면 안 된다고 하면서도 동시에 사회적 압력에 의해 지지된다는 것을 사회적 규칙의 특징 중 하나로 보고 있다. 물론 하트가 말하고자 하는 것은 사회적 압력이 직접 관계되는 것은 개개의 행위자가 아니라 규칙들이고 따라서 설령 사회적 압력에 의해 만들어진 법규칙이라고 해도 개별적인 행위자의 복종 의무의 설명에는 개별적인 행위자 관련적인 것은 개입되지 않아야 한다는 것이지만, 그는 또 다른 곳에서는 한 사회 안에서도 규칙을 수락하고 그 유지에 자발적으로 협력하는 자와 규칙을 처벌의 관점에서만 대응하는 사람들 간에 긴장관

흠에서 사람들이 타인의 재산을 존중하게 되는 최초의 동기는 노동협동을 통해 더 많은 양질의 재화를 얻고자 하는 타산적 이해관련성이다.²⁶⁾ 그러나 흠은 일단 재산권 규칙 준수의 관행이 정립되고 난 후 관행에 깃들기 시작하는 규범성 요소에 주목했다. 이는 단순히 규칙적으로 행해지는 행동유형에 규범성이 부가된다거나 하는 문제는 아니다. 관행이 정착되는 초기 단계에서 타산적 동기는 관행적 행위의 필요충분한 동기이지만 시간이 지남에 따라 공동체가 확장되고 관행의 규모가 커지면서 타산적 동기는 더 이상 관행의 유지에 충분하지 않다. 오히려 관행의 규모가 커지면 커질수록, 관행에 참여하는 사람들의 수가 많아지면 많아질수록, 관행이 요구하는 행위를 하지 않는 것이 더 자기이득에 부합하는 것일 수 있다(T499). 관행의 계속적 유지를 위해서는 통상적 관행론에서 거론되는 관행적 행동의 이유, 즉 타산적 숙고 이상의 것이 필요하다.

(2) 동기론

흠이 저렇게 두 가지 문제를 구별하고자 했던 배후에는 그의 동기론이 자리 잡고 있다. 우리가 행위를 승인하거나 비난할 때 우리가 고려하는 것은 행위의 동기로 작동한 내심의 성향이고, 외부 행태는 이 내심의 성향을 추정하는 단서일 뿐이다(T476-478). 적선 행위는 그것이 자비심의 발로로 간주되어 찬양되는 것이지 그 행위 자체가 찬양되는 것이 아니다. 적선행위가 명예욕에서 나온 것임이 알려지는 경우 우리는 칭찬을 철회하려고 한다. 역으로, 누군가가 선의를 발휘하여 타인을 돕고자 했지만 정황상 의도했던 결과가 발생하지 않았다고 해도, 이 자는 여전히 칭송된다. 규범적 승인과 내적 성향, 동기의 관계를 정리하면 다음과 같다.

계가 있다고 말함으로써 ‘내적 관점’의 논의에 자발성이라는 개별적인 행위자 관련적 요소를 포함시키고 있다. 허버트 하트(2001), 115-120면.

- 26) 흠은 누군가가 ‘첫 번째 기회’에 보여주는 평화의 행동을 계기로 사람들은 자신만이 아니라 다른 사람들도 다 함께 평화의 행동을 취할 것이라는 기대 하에 평화의 규칙을 준수하는 것이고, 바로 이러한 기대가 사람들에게 재산규칙을 지키는 동기(Motive)를 제공한다고 말한다. 또한 그는 재화의 희소성 및 불안정성, 이기심과 제한된 범주의 자비심 등을 동원하여 이뤄진 재산권규칙의 정립과정에 대한 자신의 설명을 정의의 덕에의 ‘자연적 의무’에 대한 설명이라고 하고 있다(T498).

(행위자 a 의 행위 x 가 규범적으로 승인된다.) iff (a 는 규범적으로 승인되는 성향 y 를 갖고 있었다. & a 는 성향 y 가 동기가 되어서 행위 x 를 했다.)

행위 x 가 규범적으로 승인되거나 되지 않은 것은 그것이 규범적으로 승인되는 성향 y 덕택에서 나온 것인가에 달려 있다. 성향 y 는 행위 x 의 정당성의 실체를 이룬다.

그럼, 재산권규칙의 준수행위에서는 그 동기로 어떤 성향이 말해질 수 있는가? 이 성향은 우리에게 선천적으로 주어진 ‘자연적’ 성향은 아니다. 눈앞에 굶주린 자녀를 보고도 도둑질을 하지 말아야 한다는 사회적 규칙은 자연적 성향인 모성애나 부성애와 정면으로 충돌한다. 또한 타인의 재산을 존중하여 약탈하지 말도록 하거나 빌린 돈을 돌려주거나 하는 것은 사적인 자비심(Private Benevolence)의 발현도 아니고, 공적인 자비심(Public Benevolence)의 발현도 아니다. 빌린 돈을 그대로 돌려주는 일이 때로는 당사자에게, 때로는 다수의 많은 사람들에게 해가 되는 것일 수 있다. 돈을 돌려받는 당사자가 매우 방탕하여 그로서는 많은 돈을 갖고 있는 것이 더 좋지 않은 일일 수 있고, 또는 매우 사악하여 돌려받은 돈을 타인을 괴롭히는 데 사용할 수도 있다(T482). 모성애나 자비심을 발휘하는 것은 ‘자연적’ 성향이 동기가 되어 행해진다는 점에서 ‘자연적’ 덕의 행위이지만, 재산권 규칙을 준수하는 행위는 그렇지 않다.

그러나 그렇다고 우리가 어떤 한 재산권규칙 준수행위에 대해 그 동기를 그 행위의 올바름에 대한 존경(Regard to the Honesty) 내지 의무감(Sense of Duty)라고 한다면 이는 순환론적이다(T478). 행위 x 의 정당성이 성향 y 에 의해 구성될 때, 우리는 동기 y 를 행위 x 자체의 정당성에 기인한 의무감과 등치될 수 없다. 행위자 a 의 행위 x 를 승인해야 하는가라는 질문에 대해 행위 x 는 그 자체로 정당하고 행위자 a 는 행위 x 에 대한 존경심으로 인해 행위 x 를 한 것이므로 우리는 그 행위를 승인해야 하는 것이라고는 답할 수 없다. 행위 x 의 정당성은 그 동기에 의해 주어지는 것인데, 동기의 내용 안에 행위 x 의 정당성이 전제된다면, 이는 순환론의 오류를 범하는 것이다.

(3) 인위적 덕(Artificial Virtue)과 그 동기

그러나 흄은 저러한 순환론의 오류에 대한 지적에도 불구하고 재산권규칙의

준수 행위와 관련하여 그 실재하는(Real) 동기로서의 의무감의 존재를 부인하지 않았다. 그는 말하기를, 재산권 규칙의 준수 동기가 자연적 성향도 아니요 의무감도 아니라고 하는 고찰에서 귀결되는 결론은 우리는 재산권 규칙의 준수 행위와 관련하여 ‘자연적으로’는 실재하는(Real) 보편적 동기를 갖지 못한다는 것, 그리고 그 동기는 규칙 준수의 행위 자체가 갖는 가치(Merit) 말고는 없다는 것이다. 우리의 의무감은 ‘자연’이 아닌 다른 ‘인위적’ 출처로부터, 즉 사람들 간의 관행 및 교육에서 도출된다고 봐야 하며, 그런 점에서 재산권규칙 준수의 덕은 ‘인위적 덕’이다(T483).

흄이 순환론의 오류를 운운한 것은 우리가 재산권 규칙의 준수 행위를 부모가 자녀를 돌보는 행위와 동일한 범주로 고찰할 때, 즉 자연적 덕에 기인한 행위와 같은 범주로 고찰할 때 빠지게 되는 딜레마를 지적하기 위해서이다. 만약 우리가 자연적 덕과 인위적 덕이 서로 다른 범주임을 인정한다면, 순환론의 오류는 발생하지 않는다. 규칙 준수행위의 동기는 ‘인위적’ 동기로서의 의무감이요, 이 의무감은 비록 자연적으로 주어진 것은 아니지만 일련의 과정을 통해 구성되어 ‘실재한다.’ 누군가가 재산권규칙 준수행위 자체에 대한 의무감을 갖고 있고, 이 자가 자신은 이 의무감이 동기가 되어 재산권규칙을 준수한다고 말하는 것은 무의미하지 않다. 우리가 왜 행위자가 그 행위를 정당한 것으로 판단했는가에 대해 성공적인 설명을 제시할 수 있다면 말이다. 흄의 관행론의 나머지 부분은 바로 이러한 설명에 해당한다.²⁷⁾

27) 이와 관련하여 바론(Marcia Baron)은 재산권규칙의 준수행위는 자연적 성향으로서의 동기도 없을뿐더러 ‘자연적이지’ 않은, ‘인위적’인 동기가 따로 존재하는 것도 아니라고 본다. 재산권 규칙준수의 ‘의무’란 사회유지를 위해 정치가들이 만들어내고, 또한 그 정제를 폭로하지 않았다는 점에서 흄 또한 가담했다고 할 수 있는 ‘고귀한 거짓말’(Noble Lie)에 불과하다. Marcia Baron, “Hume’s Noble Lie: An Account of his Artificial Virtues(1982), *Canadian Journal of Philosophy* 12. 필자는 흄이 다른 주제에서와 마찬가지로 이 문제에서도 피론주의적 회의주의를 견지했다고 생각한다. 피론주의적 회의주의는 단순히 의심해본다거나 부정적인 태도를 취한다는 의미가 아니라 주어진 사안에 대해 판단유보의 입장에 선다는 것이다. 피론주의자는 자신의 의식에 등장하는 현상을 기술하고 분석할 뿐 현상이 실재에 어떤 대응물을 갖는지에 대해서는 판단을 유보한다. 양선숙, “흄의 회의주의 연구”(1999), 서울대 박사학위 논문, 12-16면. 흄은 사람들이 자연적 덕의 행위에서와 마찬가지로 인위적 덕의 행위에서도 자신들이 일정한 의무감 하에서, 일정 동기하에 행동한다고 생각하고 말

(4) 의무감의 구성

그리하여 흄은 재산권규칙 준수행위의 2차적 동기로 정의에 대한 존중 (Regard to justice) 내지 의무감을 들었다(T479). 이 의무감은 다음 계기들을 통해 ‘인위적으로’ 구성된다.

- * 공감(Sympathy)과 감성의 계발(Progress of the Sentiments)
- * 정치가의 인위적 책략(Artifice of Politicians) & 부모의 훈육을 통한 내재화

앞서 언급되었듯이, 타인의 재산을 존중하는 행위를 하는 1차적 동기는 각자의 자기이득이다. 하지만 행위가 관행으로 정착되어 계속 유지되기 위해서는 새로운 동기가 필요하다. 공동체 크기가 커질수록 규모의 효과로 인해 평화유지로 인해 얻어지는 자기이득이나 개별적인 규칙위반이 가져오는 분규와 혼동으로 인한 손해는 체감지수가 낮아지기 마련이고, 자기이득은 재산권 규칙을 준수하게 하는 효과적인 동기로 작동하지 못한다.

흄은 재산권규칙을 준수하는 2차적 동기를 ‘공감’이 제공한다고 보았다. 우리는 누군가의 규칙위반 행위로 인해 또 다른 누군가가 겪게 되는 고통과 손해를 공감한다. 누군가가 겪는 불의는 그것이 아무리 멀리 있어도 우리의 기분을 불쾌하게 하며(Displease), 이는 바로 ‘공감’을 통해 일어난다(T499). 흄은 가치판단의 기원에 쾌락과 고통을 두는 흄스의 전통, 즉 각 개인은 자신에게 기쁨을 주는 것을 ‘좋다’고, 고통을 주는 것을 ‘나쁘다’고 판단한다는 입장을 이어받았는데, 그와 흄스가 다른 점은 흄은 가치판단의 주관적 기원에 머물지 않고 이러한 주관적 판단이 어떻게 공감기제를 통해 객관성을 획득하게 되는가를 규명하고자 했다는 것이다.

흄에서 ‘공감’이란 말 그대로 내가 타인의 기쁨과 고통을 말 그대로 함께 느끼는 것을 말한다. 나는 공감작용을 통해 타인이 느끼는 불쾌함/유쾌함, 고통/기쁨, 불행/행복을 함께 느낀다. 그런데 내가 함께 느끼는 타인의 정서 상태는 그것이 나와 무관한 제3자에 의해 야기되었을 때뿐만 아니라 바로 나 자신에

하고 있다는 현상에 주목했고, 바로 이런 현상에 대한 설명을 자신의 철학적 작업의 목표로 삼았다.

의해 야기되었을 때에도 마찬가지로 나의 공감 대상이 된다. 나는 나에 의해 자행된 타인의 고통 역시 함께 느끼고, 그 결과 타인에게 고통을 야기한 나 자신의 행동에 대해 ‘나쁘다’는 판단을 내린다. 나는 누군가의 고통과 불행을 자아내는 행위를 ‘일반적 조망점에서’(Upon the General Survey) 바라볼 줄 알게 되고, 객관적인 규범판단을 내릴 수 있게 된다(T499).

흠은 주관적인 쾌, 불쾌의 판단이 공감을 통해 객관성을 획득하게 되는 일련의 과정을 ‘감성의 계발’라고 칭했는데, 그는 계발 과정이 정치가의 인위적 책략과 부모의 훈육을 통해 강화된다고 보았다.²⁸⁾ 스스로 알아서 탐욕(Avidity)을 절제하는 시민이야말로 정치가들로서는 대환영이다. 재화에 대한 끝도 없는 욕망인 탐욕은 사회의 형성과 유지에 최대의 걸림돌이며,²⁹⁾ 정치인들은 이런 탐욕을 규제하여 순응적인 시민을 만들기 위해 재산권 규칙의 준수행위와 위반행위에 대해 공식적인 찬양과 비난을 조장하고 전파한다. 다른 한편, 재산과 돈 문제가 세상 평판에 얼마나 중요한지를 알고 있는 부모들은 자녀들에게 재산권규칙의 준수에 대한 존경(Regard to the Observance of Rules)을 훈육시켜 재산권 규칙의 준수행위는 명예로우며 가치 있는 것이라는 생각을 뿌리 깊게 자리잡게 한다(T500).

2. 영악한 사기꾼(Sensible Knave)의 문제

(1) 무임 승차자

저러한 인위적 동기의 존재는 역설적이게도 그런 동기를 갖지 못한 자의 사례를 통해 조명될 수 있다. 흠이 언급하는 ‘영악한 사기꾼’은 일종의 무임 승차자로서, 이 자는 발각될 위험 없이 성공적으로 재산권규칙을 위반하는 자이다. 재산권규칙의 관행은 사람들이 약탈의 이득 대신 협동의 이득을 택함으로써 성립하는데, 이 두 가지 이득은 관행의 성립 과정 중에는 양립가능하지 않다.

28) 정치가의 ‘인위적 책략’은 ‘Artifice’의 역어로서, 흠이 재산권규칙을 준수하는 행위의 덕을 ‘인위적 덕’(Artificial Virtue)으로 칭했던 사실에 비추어 ‘Artifice’가 지닌 함의를 드러내고자 ‘인위적 책략’이라고 풀어서 번역했다.

29) 흠은 탐욕이야말로 사회의 형성과 유지에 가장 파괴적인 정념(Passion)이라고 보았다. 탐욕은 충족될 줄 모르고, 영속적인, 보편적 욕망이다(T491-492).

공동체가 완전히 형성되기 전에 행해지는 약탈행위는 사회형성을 방해하여 협동의 이득을 저해한다. 하지만 일단 재산권 존중의 관행이 성립하고 난 후에는 두 가지 이득을 동시에 누리는 것이 가능하다. 영악한 사기꾼은 재산권규칙을 위반하여 부당이득을 취하는 동시에 타인들의 규칙준수 덕택으로 협동의 이득 또한 누린다(E282).

영악한 사기꾼의 존재가 가능한 까닭은 일단 재산권규칙의 관행이 대규모로 성립하면 규모의 효과에 의해 비록 일부의 위반행위가 있어도 관행 자체는 유지되기 때문이다. 가정상 이 자는 앞서 보았던 인위적 동기가 형성되지 않은 자이다. 이 자는 타인의 고통에 대한 공감능력도 없고, 정치가의 책략이나 부모의 주입식 훈육에도 세뇌되지 않은 자이다. 한마디로, 이 자는 충분한 감성의 계발을 겪지 않았다. 이 영악한 사기꾼이 규칙을 위반하는 이유는 분명하다. 규칙위반이 자신을 행복하게 만들기 때문이다.

하지만 흄은 이 자가 누리지 못하는 기쁨에 대해 말한다. 바로 인품(Character)의 향유에서 오는 즐거움이다. 품성의 고결함(Integrity)이 주는 즐거움은 훌륭한 인품을 가진 자가 스스로에 대해 느끼는 만족감으로서 이는 사치품과 향락에서 느끼는 만족감 따위와는 비할 바가 아니다.³⁰⁾ 거짓말과 위장이 행복의 경로 중 일부를 차단시키는 것은 분명하다. 모든 ‘진솔한 본성의 소유자들’(Ingenuous Natures)은 사기와 속임수에 강한 반감을 지니고 있고, 이 반감은 금전적 이득에 의해 상쇄될 수 없다. 마음의 평화나 스스로의 품성의 고결함에 대한 의식, 스스로의 행동거지에 대해 느끼는 만족감은 행복의 필수요소로서 성실한 자라면 마땅히 소중히 여겨야 할 것들이다(E283). 타인과의 대화와 교제, 지적 탐구, 건강, 자연스러운 삶의 영위가 주는 아름다움, 자신의

30) 고매한 인품의 향유에서 오는 만족감은 ‘기분 좋음’(Agreeableness)의 범주로 분류될 수 있는 성질의 것이다. 이 ‘기분 좋음’은 고매한 인품의 소유자뿐만 아니라 제3자도 느낄 수 있다. 우리는 어떤 인품이 인품의 소유자 자신에게, 또는 이 자에 의해 영향을 받는 주변 사람들에게 유용하거나(Useful) 기분 좋은(Agreeable) 것임을 인지할 때, 그 인품을 승인하게 되는 유쾌한 기분을 맛보게 된다(T590-591). 단순한 쾌락과 구분되고 유용성까지도 구분되는 ‘기분 좋음’의 독립된 범주는 후대의 밀(J. S. Mill)이 제시했던 쾌락 등급설을 연상하게 하는데, 흄의 이 ‘기분 좋음’ 개념은 키케로를 통해 계승된 스토아주의의 흔적이라고 평가할 수 있다. Sharon R. Krause, “Hume and the (false) luster of justice”(2004), *Political Theory*, vol.32 No.5 October, 632-633년.

행동을 반성을 때 얻게 되는 평화 등은 물질적 호사와 바꿀 수 없는 소중한 것들이고, 무가치한 싸구려 장난감을 얻는 대가로 이것들을 희생시키는 것은 바보나 하는 것이다. 호사스러운 삶이 주는 기쁨은 불안하고 공허하지만, 자연스러운 삶의 즐거움은 무한한 가치를 지니고 있으며, 이 즐거움을 누리기 위해 우리가 치르는 대가는 그 향유되는 즐거움에 비하면 매우 소소하다(E284).

하지만 영악한 사기꾼에게 인품의 향유가 주는 즐거움을 거론하는 것은 설득력이 없다. 만약 그가 마음의 평화 따위란 소심한 자의 자기위안에 불과하다고 평가하는 대범함을 지닌 자라면, 위장으로 점철된 삶임에도 마음의 평화를 흠뻑 누리고 있다면, 이 자에게 인품의 고결함이 주는 즐거움을 들어 설득한다는 것은 무익하다. 이 자는 자신의 기만적인 행동으로 인해 얻어지는 쾌락을 인품의 향유에서 오는 기쁨보다 선호할 것이다.

그러나 중요한 것은 흄의 관행론에서 영악한 사기꾼의 존재는 실은 아무런 이론적, 실천적 문제를 야기하지 않는다는 점이다. 흄은 이 자는 덕에의 동기(Motive to Virtue)를 상실한 자라고 말한다(E283). 재산권규칙 준수의 동기는 인위적인 까닭에, 이러한 동기가 결여된 자는 재교육을 받거나 공감능력을 키우거나 하는 감성의 계발을 제대로 겪지 않고서는 치유될 수 없지만, 만약 이런 사기꾼들의 수가 적어서 다행히 재산권의 관행이 계속 유지된다면, 그것으로 족하다.

관행론은 다수의 사람들이 행하는 수렴적인 행동에 초점이 맞춰져 있는 이론이고, 흄의 이론 역시 마찬가지이다. 흄은 재산권규칙들이 이해관계와 갖는 관계에 대해 매우 ‘독특하다’고 표현한다. 누군가가 재산권규칙 준수 행위를 했을 때, 만약 이 자의 준수행위에 다른 사람들이 공조하여 똑같이 하지 않는다면, 그 행위가 단독으로만 고려된다면, 그 행위는 사회 전체 또는 행위자 자신에게 매우 큰 손해를 끼치는 것일 수 있다. 하지만 개별사례가 주는 손해는 재산권규칙의 지속적 실행이 주는 이익에 의해 보충되고도 남는다. 재산권규칙의 준수행위 전체의 구도(Scheme)는 사회유지에 절대적으로 기여하며, 각 개인의 복지 또한 이에 달려 있다. 사람들은 경험을 통해 사회의 다른 성원들에 의해 함께 행해지는 규칙준수 행위들의 전 체계(Whole System of Actions, Concurred in by the Whole Society)가 사회 전체에게, 그리고 개개인에게 유익하다는 것을 안다(T497). 관행이 유지되는 한, 일부 일탈적인 행위는 이론적으

로도, 실제적으로도 별 위협이 되지 못한다. 제도적 관점에서 봤을 때, 영악한 사기꾼은 그 존재가 재산권제도의 유지를 저해하지 않는 이상 교화되어야 할 이유도 없고 필요도 없다.

(2) 흄의 대답

앞서 우리는 통상적인 관행론의 문제점들, 즉 통상적 관행론에서는 좋은 관행과 나쁜 관행의 개념적 구분이 어렵다는 점, 관행적이지 않은 법복종 행위에 대한 설명이 미흡하다는 점, 그리고 사람들의 행위를 결정하는 데 있어서 다른 그 어떤 근거보다 우월적인 지위를 차지하는 법의 우선성을 수용하기 어렵다는 점 등이 있음을 살펴보았다.

이제 우리는 흄의 이론을 빌려 위의 세 가지 지적에 대해 다음과 같이 답할 수 있다. 먼저, 나쁜 관행은 만약 그것이 누군가의 고통을 야기하고 공동체 형성이 주는 공동의 이득을 해치는 것이라면 공감기제를 통한 객관적 승인을 얻지 못할 것이고, 인류의 감성이 계발되는 과정을 통해 적절하게 걸러질 것이다. 나쁜 관행은 단기적으로, 국지적으로 유행할 수는 있어도 장기적으로, 대규모로 지속적으로 성립될 수는 없다.

그럼, 관행적이지 않은 법복종 행위, 즉 소라테스의 사례에서처럼 사법결정에 순응하는 정당한 행동이지만 다수에 의해 반복적으로 행해지지도 않고 행위자의 자기이득과도 합치되지도 않는다는 점에서 일견 ‘관행적이지’ 않은 행동은 어떻게 설명할 수 있을까? 가능한 한 가지 설명은 누군가가 사법결정에 불복종함으로써 다수가 입게 되는 고통에 주목하라는 것이다. 자신의 사형 언도 판결에 복종하는 것은 관행적이지 않지만 판결에 복종하는 것 일반은 관행적일 수 있고, 그것이 관행으로 성립하는 근거는 불복종행위는 그것을 지켜보는 다수에게 심적 고통을 안길 수 있으며 또한 불복종으로 인해 사법체제의 권위가 훼손되어 원활하게 작동하지 않음으로써 우회적으로 사람들에게 손해를 입힐 수 있다는 것이다.

그러나 더욱 적절한 답은 규칙준수의 의무감에 호소하는 것이다. 이 의무감은 비록 인위적으로 일련의 과정을 거쳐 형성되거나 주입된 것이기는 하지만 실재하며, 모든 다른 행위 근거를 제압한다. 이런 점에서 흄의 관행론은 법의 권위에 대한 이론이기도 하다. 그의 이론은 공동체에서 화자가 일정 규칙에 부

여하는 규범적 확신의 형성을 설명한다. 영악한 사기꾼의 존재가 문제되지 않는다고 해서 그 자에게 결여되어 있는 것, 즉 내적 의무감이 중요하지 않은 것은 아니다. 제도가 유지되는 까닭은 대부분의 사회성원들이 그가 결여한 저러한 의무감을 갖고 있고, 대부분 그에 따라 법을 준수하고 있기 때문이다.

그리하여 흄에서는 규칙준수의 의무감과 타산적 고려가 서로 다른 범주의 것임이 드러난다. 타산적 고려는 규칙의 성립을 설명하지만 규칙 자체의 규범성을 설명하지는 못한다. 규칙에의 복종행위와 무임승차는 동등하게 합리적인 것이 아니다. 타산적 숙고는 우리에게 법에 복종하는 것만큼이나 법에 복종하지 않는 것도 때로는 허용된다고 말해주지만, 의무감의 층위에서는 또 다른 판정이 내려진다. 재산권규칙에 대한 복종의무는 자기이익과 무관하게 ‘법의 이름으로’ 성립한다.

VI. 결 어

이상의 고찰에서 우리가 알 수 있는 것은 흄에서 재산권 존중과 관련한 관행적 행위의 전형은 타산적 고려에 따른 행동이 아니라 의무감에 기인한 행위라는 점이다. 이는 통상적 관행론과 흄의 관행론의 결정적 차이를 드러낸다. 앞서 우리는 통상적인 관행론에서는 외부 행태적으로는 관행에 부합하지만 그 이유가 타산적이지 않은 행동의 경우 ‘관행적’ 행동으로 평가되지 않는다는 점을 살펴보았다. 이제 우리는 흄에서는 오히려 반대의 경우가 성립한다는 것을 알 수 있다. 흄의 관행론에서 관행적 행동의 전형은 타산적 이유에 의한 행동이 아니라 오히려 의무감에 의한 행동이다. 영악한 사기꾼은 바로 이 의무감의 적절한 계발에 실패함으로써 오직 타산적 이해관계만을 자신의 행위 이유로 고려하는 자이고, 흄의 이론에서 이 자는 그저 타산적 행동을 하는 자일 뿐 관행적 행동을 하는 자는 아니다. 이 점에서 흄의 이론은 그리んの 비판을 넘어선다.

하지만 그렇다고 흄의 이론이 규칙 준수행위의 동기에 대한 완전한 이론이라고 할 수는 없을 것 같다. 우리는 흄에서 재산권규칙의 준수와 관련하여 그 인위적 동기로서의 의무감이 구성되는 계기들, 즉 공감, 감성의 계발, 정치가의 책략 및 부모의 훈육 등에 대해 살펴보았다. 또한 영악한 사기꾼에서는 그 자

가 결여한 것으로서 인품의 향유와 내적인 마음의 평화 등이 지적된다는 것도 검토했다. 문제는 이러한 흠의 설명에는 조화롭지 않은 두 가지 종류의 논의가 혼재되어 있다는 것이다. 흠은 한편으로는 정치가의 책략과 부모의 훈육에 의해 주입되는바 재산권 규칙 준수에 대한 존경심 내지 의무감을 말한다. 이것들은 재산권규칙 준수의 2차적 동기로서 모든 타산적 이유를 압도할 뿐만 아니라, 모든 자연적 성향에 대해서도, 사적인 자비심에 대해서도, 공중일반의 이득에 대한 관심에 대해서도 우월적으로 작동한다. 하지만 다른 한편, 흠은 공감을 통해, 또는 고매한 인품의 향유에서 오는 즐거움을 얻고자 하여 규칙을 준수하는 경우도 있음을 말한다. 공감에 의해 함께 느끼는 누군가의 고통은 나의 자발적인 규칙 준수의 계기가 될 수 있고, 고매한 인품에 대한 긍지 또한 나를 자발적인 규칙 준수행위로 이끈다. 그러나 이러한 공감과 자긍심, 내적 성찰에 의해 규칙을 준수하는 것과 저렇게 여타의 모든 이유들을 무시하고 오직 규칙 그 자체에 대한 존경에 의해 규칙을 준수하는 것은 결코 동일한 것이 아니다.

흠이 저러한 혼합된 설명을 제시하는 것에 대해 필자는 우리 인간에게는 본래 규칙 준수의 동기를 이해하는 두 가지 접근법, 또는 규칙을 준수하는 두 가지 경로가 있는 것은 아닌가 하는 생각을 갖고 있다. 성찰적 복종의 경로와 기계적 복종의 경로가 그것이다. 이 둘 중 심정적으로 옹호하는 것을 고르라면 선뜻 전자를 고르겠지만 그럼에도 전자가 후자와 어떤 연관성을 맺는 것인지, 성찰적 복종이 전제하는바 수범자의 자발성이 어떻게 이론적으로 해명될 수 있는지는 지속적인 연구가 필요한 과제이다. 우리가 법적 의무의 해명을 법학의 영역에서 아예 삭제하자는 빈더의 예를 따르고자 하는 것이 아니라면 말이다.³¹⁾

31) 한스 벨첼은 신칸트학과 법철학을 법실증주의의 보완이론이라고 평하면서 빈더의 주장을 인용했다. 빈더는 법해석학의 상식적인 출발점이 되어버린 법의무 개념은 거부되어야 하며, 의무는 법학적 논의에서 다뤄야 할 법적 개념이 아니라고 주장한다. 피지배자의 의무라고 하는 일반적 범주나 범죄를 저지르지 말라는 형사법적 의무나 의무를 이행하라는 민사법적 의무는 거부되어야 한다. 실제로 법에서 문제가 되는 것은 의무가 아니라 책임일 뿐이다. 한스 벨첼, 『자연법과 실질적 정의』(2002), 박은정 역, 삼영사, 268-269면.

Abstract

Law and Obedience in Legal Conventionalism

Yang Sunsuk

Leslie Green criticized conventionalism for its unsuccessful explaining of the fundamental phenomena of law such as normativity, authority, and obedience to legal rules. Law functions as an exclusionary reason on human conducts, and overwhelms all the other prudential reasons. The standard legal conventionalism, whose basic features are borrowed from David Lewis' convention theory, refers to one of the prudential reasons, the self-interest, in explaining of why people are following legal rules. But Green's criticism is not relevant all sorts of conventionalism, especially not to Hume's. Hume's conventionalism, which is mainly concerning the establishment of property rules, comprises two parts. One is a descriptive research of under what conditions human society comes to be equipped by property rule convention, and the other part is a study on why people judge the rule following acts to be just, and on under what sense of duty they accommodate their conducts to the rules. This paper tries to reformulate Hume's conventionalism through the contemporary game theory conceptual tools such as Schelling points, and to show that Humean conventional rule following acts are not the merely externally observable ones, since they are conducted from the internal viewpoint, i.e. the sense of duty.

색인어

데이비드 흄(David Hume), 관행론(Conventionalism), 재산권규칙(Property Rules), 셸링 포인트(Schelling Points), 의무감(Sense of Duty)